

1503173-43.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... que os fatos são verdadeiros. Realiza tráfico de drogas desde os 15 anos de idade. No dia em que foi preso estava realizando tráfico desde às 8h. Não estava trabalhando pois estava pagando a dívida. Não fazia uso de drogas. Na primeira vez que foi preso foi preso com drogas e a dívida veio dessa prisão. Trabalhou como empacotador. Morava na rua. O dinheiro que foi preso era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n º01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503173-43.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503173-43.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2346168/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 22056621 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 4092/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2346168 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SANTOS foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, segundo denúncia, em 20 de dezembro de 2021, por volta das 13 horas, na Estrada Municipal do Taboão, 1000, Chácara Bom Tempo, em Franco da Rocha, trazia consigo, com a finalidade de entrega a consumo de terceiras pessoas, 25,99g de cocaína em forma de "crack", fracionada em 76 unidades, 82,43g de tetrahidrocannabinol, droga popularmente conhecida como maconha, acondicionada em 56 porções, e 34,44g de cocaína, dividida em 213 tubos plásticos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08, laudo de constatação preliminar de fls. 10/15 e laudo químico-toxicológico de fls. 64/66, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 76), o réu foi citado (fls. 89) e apresentou resposta à acusação às fls. 96/97.

Durante a instrução, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e realizou-se o interrogatório do acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, a desclassificação para o delito de porte de droga para uso pessoal e, subsidiariamente, a aplicação de pena mínima.

É o relatório

Passo a decidir.

Preliminarmente, não há que se falar em irregularidade da atuação dos guardas municipais.

Como sabido, o tráfico de drogas é delito de natureza permanente. Nesta categoria de infrações, o sujeito pratica uma violação da norma penal que se prolonga no tempo. Estará, portanto, em constante estado de flagrância enquanto perdurar a conduta criminosa (art. 303 do CPP).

O Código de Processo Penal, em seu art. 301, permite que qualquer pessoa do povo efetue prisão de quem se acha em flagrância delitiva. É cediço que o art. 144, § 8º, da Constituição Federal determina que a Guarda Municipal será destinada à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo, portanto, como principal função a de assegurar a segurança pública, tampouco investigar a prática de crimes. Nada obstante, a referida disposição não significa que a guarda municipal não possa prender em flagrante aquele que estiver cometendo um delito. Tal entendimento não discrepa da posição consolidada pelos Tribunais Superiores:

Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer um do povo pode prender aquele que estiver em flagrante delito. O fato da prisão em flagrante do ora paciente ter sido realizada por Guarda Municipal não revela ilegalidade" (STJ, HC nº 394.112/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03/08/2017)

No mais, merece destaque que, pelo Estatuto Geral das Guardas Municipais, que disciplina o referido art. 144, § 8º, da Constituição, é competência específica das guardas municipais colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social (art. 5º, IV), bem como encaminhar ao Delegado de Polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração penal (art. 5º, XIV).

Neste caso, os guardas receberam denúncia anônima que apontava as características do réu como participante do tráfico de drogas e presenciaram a atitude suspeita dele que empreendeu fuga quando da aproximação da viatura. Assim, era presumível que ele pudesse estar cometendo um delito, não tendo sido a ação dos guardas decorrente de qualquer investigação prévia, sendo evidente que a atitude do réu não é a que se espera de um transeunte ao avistar agentes do Estado.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime vem demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 05/07), do auto de exibição de apreensão (fls. 08), pelo laudo de constatação acostado a fls. 10/15 e laudo pericial definitivo acostado às fls. 64/66, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu negou os fatos.

Em juízo disse que os fatos são verdadeiros. Realiza tráfico de drogas desde os 15 anos de idade. No dia em que foi preso estava realizando tráfico desde às 8h. Não estava trabalhando pois estava pagando a dívida. Não fazia uso de drogas. Na primeira vez que foi preso foi preso com drogas e a dívida veio dessa prisão. Trabalhou como empacotador. Morava na rua. O dinheiro que foi preso era fruto do tráfico de drogas. Quando foi preso, foi alvejado com um tiro no braço que passou de raspão.

Sua versão encontra-se em consonância com o cenário probatório obtido.

A testemunha Keiler Barboza da Silva, guarda municipal, disse que estavam em patrulhamento e receberam denúncia anônima narrando sobre suposta prática de traficância no local dos fatos. Lá chegando, avistaram um indivíduo que foi identificado como sendo o réu. Este, ao ver a aproximação da viatura, empreendeu fuga. O indivíduo foi acompanhado a pé pelo seu colega de guarnição que conseguiu alcançá-lo. Em busca pessoal, foi encontrado em posse de Matheus, no interior de uma bolsa, porções variadas das drogas descritas no boletim de ocorrências tratando-se de maconha, cocaína e crack. Não viu nenhuma movimentação similar a venda. Dentro da bolsa havia dinheiro também. Questionado, o réu confessou os fatos. Não havia outras pessoas no local e apenas o réu correu para dentro do condomínio, que tinha o portão fechado. Quem abriu o portão para a guarda municipal foi a pessoa da portaria e não sabe se o réu morava no condomínio. Não se recorda como era a bolsa, mas estava pendurada de posse do réu.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Marcio Alexandre da Silva, que apenas acrescentou que estava averiguando uma denúncia de tráfico de drogas em um condomínio. A denúncia dava conta de que um indivíduo estava realizando tráfico de drogas sendo passadas as suas características. Ao chegar ao local depararam com o réu, que tinha as mesmas características da denúncia. Ao ver a viatura, ele correu, sendo abordado de posse de uma bolsa ou sacola que continha drogas e uma quantia em dinheiro trocada em seu interior, não se lembrando da quantidade. Não se recorda se o réu residia nesse condomínio, mas o local é conhecido ponto de tráfico de drogas.

Quanto aos guardas municipais ouvidos, não há indícios de que tinham motivos para acusar o réu de forma leviana e gratuitamente, até porque sequer o conheciam.

Neste diapasão:

"Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido."(JTJ 208/273).""Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT614/275).

Prova. Tráfico de entorpecentes. Depoimento de policiais Valor no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a palavra de policiais, quando esclarecedora e detalhada, além de respalda danos elementos indiciários colhidos, constitui prova hábil para a condenação, ainda mais se as testemunhas da defesa não puderam desfazer a versão por eles relatada em juízo."(TACrim, 12ª Câmara, rel. Desembargador João Morenghi, Apelação1473255/5).

Assim, não procede a afirmação de inexistência de provas suficientes para a condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas. Observo, ainda, que os depoimentos foram coerentes e harmônicos, de modo que eventual discrepância, se houve, não foi suficiente para retirar o valor probante que deles emana. A quantidade de droga apreendida, e os depoimentos prestados pelos policiais militares ouvidos, levam à certeza de que o acusado guardava e transportava drogas na ocasião, impondo-se pois a sua condenação. Por fim, cabe assinalar que a denúncia imputa ao réu a conduta de “ter em depósito, guardar, e transportar, para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente”, e não de vender drogas, razão pela qual os fatos descritos na denúncia encontram-se perfeitamente provados em instrução. Ainda, há de se mencionar que o fato de ser ou não usuário de entorpecentes, não afasta a situação de traficância e portanto, não há que se falar em desclassificação do delito.

A condenação, portanto, é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Sopesados os elementos norteadores do art. 59 do Código de Penal e o art. 42 da lei 11.343/06, entendo que a quantidade de drogas apreendida foi expressiva e merece exasperar a pena. As demais circunstâncias judiciais foram as típicas à espécie. Assim, elevo a pena em 1/8 fixando-a em fixo a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes a incidir na espécie. Presente a atenuante da confissão, razão pela qual a pena retorna ao mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento. Entendo não ser aplicável a redução de pena prevista no §4º do art. 33 ao caso.

Insta asseverar, oportunamente, que os requisitos previstos na causa de diminuição do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas ou não participação em organização criminosa) são de observância cumulativa. A ausência de qualquer deles implica o afastamento da causa de diminuição de pena.

Nesse rumo, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por

tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque "assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito". Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça" (EResp 1.431.091/SP, Terceira Seção, de minha relatoria, DJe 01/02/2017).

O réu possui condenação em primeira instância pelo mesmo tipo penal, ainda pendente de trânsito em julgado, a corroborar o entendimento de que utilizava-se do tráfico de drogas como meio de vida. Ainda, admitiu em juízo que não tinha atividade laboral lícita desde os 15 anos de idade dedicando-se exclusivamente ao tráfico de drogas como meio de vida.

Nos termos dos artigos 49, parágrafo 1º, e 60, caput, ambos do Código Penal, considerando a condição econômica do réu, fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença. Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

A pena será cumprida no regime inicial semiaberto, uma vez que o réu é primário, nos termos do que determina o art. 33 do CP.

Ante o exposto e o mais do que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e condeno MATHEUS HENRIQUE DA SILVA SANTOS qualificado nos autos, como incurso nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, no mínimo legal

Tendo respondido o processo preso, o réu não poderá aguardar o trânsito em liberdade eis que subsistem os motivos ensejadores de sua prisão, em especial após a prolação de sentença condenatória a pena de 05 anos de reclusão.

Decreto, portanto, o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos do artigo 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Com o trânsito em julgado, anote-se o resultado definitivo no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça. Expeça-se guia à VEC

P.I.C.

Franco da Rocha, 28 de Julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA